

1500513-34.2019.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... Prado, informa que receberam denúncias de tráfico de drogas no local, mas ninguém foi localizado. Depois receberam informações sobre o Bryan, que estava foragido e foram ao local e avistaram os réus em movimentação típica de tráfico de drogas. Rivaldo abordou Douglas, mas Brayan não foi contido. Não há nenhuma dúvida de que era o Brayan porque ele é bem conhecido dos meios ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500513-34.2019.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500513-34.2019.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2367984/2019 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 9182487 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2835/19/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2367984 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2835/19/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2367984 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2835/19/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2367984 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2835/19/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2367984 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2835/19/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA MAMEDE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Douglas de Oliveira da Silva Mamede e Brayan Richard Silva Reis, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, eis que no dia 21 de dezembro de 2019, por

volta das 15h40, na Avenida Benedito dos Reis Scigliani, Buenos Aires, agindo em conluio e previamente ajustados com divisão de atos executórios, vendiam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 24 microtubos plásticos contendo cerca de 40g de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial, que no ato da abordagem, os denunciados perceberam e se colocaram em fuga. Douglas de Oliveira da Silva Mamede foi contido e, em revista pessoal foi encontrado na sua posse a quantia de R\$15,00 em dinheiro. Brayan Richard da Silva Reis, por sua vez, conseguiu êxito na fuga.

A denúncia de págs. 72/73 veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/65.

Deferida prisão preventiva do réu Bryan Richard da Silva Reis. (págs.74/77).

O réu Bryan, manifestou-se às págs. 125/132 e acrescentou documentos às págs. 133/132 aduzindo que houve erro judiciário originário da confusão dos policiais militares na atribuição de identificação da pessoa do indiciado. Requer que seja concedida a liberdade provisória em favor do réu, com aplicação de medidas cautelares.

Revogada a prisão preventiva do denunciado e impostas medidas cautelares, conforme págs. 140/141.

A denúncia de págs. 72/73 foi recebida aos 20 de fevereiro de 2020.

O réu Bryan Richard da Silva Reis foi devidamente citado e apresentou defesa prévia as págs. 147/155, onde sustenta que houve equívoco por parte dos policiais ao confundir o réu com outra pessoa. Requer que seja julgada improcedente a denúncia.

O réu Douglas Oliveira da Silva Mamede, apresentou defesa preliminar nas págs. 189/205, sustentando que a denúncia é inepta, requerendo a absolvição do réu e que caso o julgado culmine em uma possível condenação, pleiteia a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório dos acusados, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra disponível aos interessados - pgs. 310/312.

O Ministério Público manifestou-se nas pgs. 316 indicando diligências pendentes de cumprimento que seriam necessárias ao julgamento da causa. Nas pgs. 320 indicou incorreção quanto ao número de telefone sobre o qual deveria ter incidido a quebra de sigilo, requerendo prazo para a vinda de informações corretas e o processamento delas.

Sobreveio deliberação judicial nas pgs. 323/324.

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal. Indica que a autoria está comprovada, assim como a materialidade. Após exposição da prova oral angariada, pois "os policiais viram os acusados no local dos fatos praticando o tráfico de drogas e, após abordagem, a despeito de BRAYAN ter fugido, DOUGLAS foi detido e as drogas que estavam sendo por eles negociada foram arrecadas pelos Policiais justamente onde eles viram os acusados pegando os entorpecentes que seriam destinados a entrega de usuários / compradores" (pgs. 342). Indicou nove pontos pelos quais a negativa de Brayan deve ser desconsiderada. Requer o aumento de pena em relação a Douglas, por força do passado infracional e quantidade de entorpecentes apreendida. Em relação a Brayan, alega

que ele também ostenta passado infracional desabonador e passagens também após a maioridade. Requer a fixação do regime inicial fechado e afastamento do privilégio, pois ambos dedicam-se a atividades criminosas. Acrescentou os documentos de pgs. 348/353.

A defesa do réu Douglas requer a absolvição por insuficiência de provas. Pugna pelo benefício da dúvida, ressaltando que não foram apreendidas drogas em poder do acusado e há dúvida sobre a destinação do entorpecente. Requer a desclassificação para os moldes do art. 28 da lei de drogas. Alternativamente, para fins de dosimetria, indica a primariedade e bons antecedentes do réu, sendo possível a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ressalta a inconstitucionalidade do regime inicial fechado para o caso de tráfico privilegiado - pgs. 357/360.

A defesa do réu Brayan, por sua vez, sustenta que a quebra de sigilo telefônico não prejudica o réu, negando que Lilian seja proprietária da linha telefônica 19-99252-9923. A quebra de sigilo de Jhonatan também nada localizou capaz de incriminar o réu. Sustenta a negativa de autoria diante de alibi, pois no dia dos fatos Lilian repassou pedido de Brayan para que a mãe ficasse com o filho do casal para que pudessem sair e que às 18:13 do dia 21.12.2019 estavam prontos para saírem com amigos. Indicou a declaração de pgs. 97 de que Brayan não se encontrava no local dos fatos e que Jhonatan seria a pessoa que correu da polícia militar. Indicou outros elementos nos quais sustenta que Brayan está sendo confundido com Jhonatan. Conclui que havendo conflito entre a presunção de inocência e a presunção de legalidade dos atos praticados por policiais deve prevalecer a primeira. Requer a absolvição do réu ou a aplicação de pena mínima por tráfico privilegiado, acrescentando o documento de pgs. 376/377.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (pág. 12), auto de constatação preliminar (pág. 13) e pelos laudos periciais de páginas 173/175.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

A quebra de sigilo telefônico nada apurou em desfavor dos acusados.

Acerca da prova oral, convém analisar a síntese do que foi exposto em audiência para maior clareza:

Rivaldo Luciano Tonhão relata que no período da manhã, aquele dia, houve uma movimentação de tráfico de drogas e na hora do almoço observaram a movimentação dos

dois. Bryan estava foragido da Justiça. Havia revezamento entre eles na venda de drogas. Bryan saiu correndo. Douglas foi abordado pela viatura de apoio. Com Douglas havia dinheiro. O depoente encontrou os pinos de cocaína. Brayan conseguiu evadir-se. Ambos eram conhecidos dos meios policiais. Não conhece Jhonathan. Saíram no encalço do Bryan e em outra audiência houve uma outra conversa semelhante dele. O comandante tinha identificado o Bryan na parte da manhã. Reconhece Bryan na foto de pgs. 133 e não reconhece Jhonahan. Não se lembra a calça do Bryan. Ficaram em observação a uma distância de 30 a 40 metros. Foram fazer a abordagem por causa de uma solicitação do COPOM que disse que o Douglas estava lá traficando. Foram até o local e não localizaram.

Emílio Mariano do Prado, informa que receberam denúncias de tráfico de drogas no local, mas ninguém foi localizado. Depois receberam informações sobre o Bryan, que estava foragido e foram ao local e avistaram os réus em movimentação típica de tráfico de drogas. Rivaldo abordou Douglas, mas Brayan não foi contido. Não há nenhuma dúvida de que era o Brayan porque ele é bem conhecido dos meios policiais e quando ele corria acompanhou ele de perto e não tem nenhuma dúvida de que seja o Bryan. A denúncia na parte da manhã foi repassada pelo Sargento Gilmar. Não conhece Jhonathan de Paula. Não conhece lembrar a vestimenta da pessoa que vestia. A calça era preta. Não se recorda se havia listras amarela ou vermelha. Não conhece Jhonathan e analisando a fotografia de pgs. 133 não acha semelhante a Bryan. Não se recorda da calça de pgs. 137. Fizeram a verificação durante vinte minutos antes da abordagem. Na posse do Douglas não havia entorpecente.

Gilmar Donizetti da Cruz informa que nessa data foi na casa da sua mãe, que mora ali no bairro. O Douglas mora por ali. Sabia que havia mandado de prisão contra o Bryan. Viu o Douglas sentado no chão e um rapaz junto com todas as características lembrando o Bryan. Douglas deu um toque e o outro rapaz não olhou o depoente de frente. Foi até a casa da sua mãe e ligou para o 190 e disse que tinha visto o Brayan por ali. O Douglas acabou sendo preso. Não pode afirmar que o indivíduo era o Bryan porque ele não ficou de frente. A calça era preta, com riscos na lateral. Com risco amarelo, vermelho e branco. Os riscos eram detalhes nas laterais. Bryan tinha clareado um pouco o cabelo, estava de "luzes". A calça é muito semelhante àquela que viu o rapaz usando na avenida.

Ariane disse que estava no local. Douglas estava sentado. Douglas foi abordado. Jhonathas correu. Não era o Brayan. Não viu se a polícia encontrou algo com o Douglas. O Douglas foi preso. Não tentou conversar com os policiais. Conhece tanto Jhonathan quanto Bryan. Seu irmão é amigo dos dois, tanto do Jhonathan quanto do Brayan. Viu ele subindo, tentando sair daquela situação. Não lembra a roupa que ele estava vestindo. Não se lembra de qualquer detalhe na calça que tenha lhe chamado a atenção. Não sabe se a droga poderia ser dele ou do Jhonathan, mas seu irmão é usuário do cocaína. Moram perto do local da abordagem. Brayan se mudou para o local. A testemunha estava longe da abordagem, não muito perto. Dava para ver a abordagem. Umas 3, 4 casas. Bryan não estava por ali. Eles são um pouco semelhantes fisicamente. São morenos, altos e com cabelo parecido. Não sabe dizer onde Douglas.

Talita é mãe do Jhonathan. Só ficou sabendo porque um vizinho foi lhe perguntar se Jhonathan tinha sido preso. Jhonathan estava lá embaixo junto com o Douglas. Foi nessa situação que Douglas foi preso. Não sabia que Jhonathan tinha amizade com o Douglas. Jhonathan foi para a casa da sua mãe e não mora mais com a depoente. Conhece o Bryan de vista. Ele tem semelhança com o Jhonathan. Ele correu e foi para o lado da casa do seu ex-marido. Sua mãe já tinha marcado de ir buscar ele. O seu ex-marido falou que não queria saber de polícia na porta da sua casa. A polícia não foi atrás de Jhonathan na casa da depoente. Mais de um vizinho perguntou se Jhonathan teria sido preso. O comentário dos vizinhos foi sobre Jhonathan ter corrido naquela situação em que Douglas foi preso. A casa do ex-marido fica 3 quadras próximas da avenida Benedito dos Reis Sigliani. O ex-marido disse que Jhonathan estava tentando pular o muro da casa para fugir da polícia. Jhonathan tem

uma calça tal como aquela da fotografia. Confirma que o número de celular era de Jhonathan- 19-99581-7734. Morava na rua Maria Boaro que fica próximo da avenida. Fica a quatro quadras.

Bryan Richard da Silva Reis, em seu interrogatório, declarou que os fatos não são verdadeiros. Disse que estava em casa com sua namorada e seu filho, na vila Maschietto. Acabou preso em outro processo e ficou sabendo que estava sendo acusado também neste processo. Não houve flagrante e nem foi visto no local. Estava na casa da sua namorada. Tem celular. Lilian também tem. Na época dos fatos não tinha celular. Como estava com a Lilian, não tinha celular. Tem celular atualmente. Ficou sabendo que Jhonatan estava com Douglas e estaria sendo confundido com o depoente. Na época dos fatos, seu filho era recém-nascido e moravam na vila Maschietto e estava permanecendo em casa. Não conhece Douglas.

Douglas Oliveira da Silva Mamede disse que é usuário de cocaína, estudou até a 8ª série e foi preso faz tempo, por tráfico. Não foi para a Fundação Casa quando era menor. Disse que entrou no mato para urinar e quando virou para trás a polícia estava no meio do mato. Assustou. Tinha uma viatura na rua. Saiu correndo e foi desmaiado por um policial que lhe abordou. Desmaiou quando foi imobilizado. Estava sozinho no mato. Estava ali porque mora naquele bairro. Estava andando na rua e entrou no mato para urinar e correu porque assustou-se com a polícia. Teve um problema no passado com os policiais. Confirma que ia usar a droga no mato. A droga que acharam não era sua. A que estava em sua propriedade jogou fora. Eram dois pinos só. Entrou no mato para urinar e não ia usar droga lá. Tinha consigo dois pinos de cocaína. Dispensou na rua. Não conhece a pessoa que falaram que estava junto do depoente. Estava realmente sozinho. Não conhece o Brayan. Não conhece Jhonathan. Não viu Brayan naquele local. Também não ficou Jhonatan. Além do depoente não viu ninguém correndo. Também não viu Ariane do local em que estava. No local que estava havia apenas o depoente e os policiais. O local da abordagem foi na biqueira, mas não sabe o nome da rua.

2 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a “lei do silêncio”, extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes fora dos quadros dos órgãos empenhados no combate à criminalidade.

No que se refere a Douglas, detido no local, ambos os policiais foram uníssomos em dizer que visualizaram indivíduos na prática da traficância, onde se revezavam para atender os usuários que transitavam pelo local. Durante a aproximação para abordagem, eles empreenderam fuga, sendo apenas um deles detido. O local da apreensão das drogas era uma avenida. Pelo horário da abordagem, 15h40, por ainda havia pessoas transitando no local.

Nada faz crer que os policiais pudessem ter consigo 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos contendo cocaína para indevidamente “forjar” cidadãos, colocando suas carreiras em risco a fim de aprisionar pessoa com a qual não mantém qualquer

desafeto ou problema pessoal, nem tampouco incriminá-la indevidamente, sobretudo no específico local público com presença de outras pessoas, em um sábado, 15h40 da tarde.

A quantidade de drogas apreendida, assim como de numerário - R\$ 15,00, aliadas ao fato de que o réu foi abordado em ponto de tráfico desta cidade e teria sido observado desde a parte da manhã em movimentação típica de tráfico é suficiente para a condenação.

Em suma, em relação ao réu Douglas o caso sub examen evidencia a prática de crime diverso do simples porte para uso exclusivo e pessoal de entorpecentes. Revela, na verdade, manutenção de drogas para entrega também a terceiros, ficando afastada a possibilidade de desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Presente a tipicidade delitiva na forma capitulada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu Douglas, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

Entretanto, no que se refere ao réu Brayan, instalou-se dúvida razoável sobre a autoria.

Em que pesem os argumentos ministeriais expostos nas pgs. 342/345, a defesa contra-argumentou com propriedade nos seus memoriais.

Não está descartada a hipótese de equívoco na identificação feita à distância pelos policiais militares que não lograram efetuar o flagrante de Brayan na ocasião.

Conforme decisão de pgs. 138/141 que revogou a prisão preventiva do denunciado "a ordem pública também só é mantida quando os verdadeiros criminosos recebem a reação do Estado. A mera possibilidade de punição de inocente viola a ordem pública de forma tão profunda quanto o crime de tráfico."

Naquela ocasião também constou que "O depoimento de pg. 119, da própria mãe de Jhonatan, indica ser possível que ele esteja sendo confundido com o denunciado Brayan. Nas pgs. 123, o Sargento Gilmar Donizete, diz que o fugitivo "parecia ser Brayan" e que "não conseguiu confirmar ser realmente a pessoa de Brayan, porém pela atitude e características físicas acreditava ser o Brayan". As fotos de pgs. 133 convencem este Juízo de que há realmente muita semelhança entre Brayan e Jhonatan. Há chance potencial de que a distância e a agitação inerente a um procedimento de prisão em flagrante em local aberto possam ter prejudicado a clareza na identificação do fugitivo. O documento de pg. 101/102, apesar da imprecisão apontada pelo Ministério Público sobre a data, deixa evidente que Jhonatan manifestou a intenção de assumir sua responsabilidade."

Em Juízo, a mãe de Jhonatan confirmou que seu filho estava em companhia de Douglas na ocasião em que ele acabou preso. Sustentar que seu depoimento é inverossímil apenas porque não teria conversado com seu filho sobre os fatos não se afigura adequado, a meu sentir. Ao revés, a experiência demonstra que geralmente as mães de traficantes são omissas ou deveras permissivas com as condutas dos filhos menores, afigurando-se perfeitamente possível a "cegueira deliberada" da genitora em relação aos malfeitos do filho.

A amizade virtual entre Brayan e Douglas na rede social facebook não autoriza

nenhuma conclusão em desfavor do réu. A propósito, muito comum que pessoas que nunca conversaram e se conhecem apenas "de vista" ou nem isto, aceitem pedidos de amizade em redes sociais e continuem sem qualquer comunicação direta, a despeito do canal aberto criado. A aceitação de amizade virtual pode evidenciar um propósito de amizade que pode vir a se concretizar ou não. Claro que pode realmente indicar uma amizade real pré-existente. Todavia, ambos os réus negam e não há provas em sentido contrário.

Há de fato semelhança física entre Jhonatan e Brayan e o Juízo não pode conviver com a dúvida de ter imposto condenação a inocente, notadamente quando a antítese defensiva está calcada em contraprova hábil a suscitar incerteza quanto à pertinência subjetiva passiva da ação penal.

O corréu Douglas disse que estava sozinho na ocasião, de modo que também não incrimina Brayan.

Em suma, os diversos contrapontos defensivos são suficientes para trazer dúvida insuperável.

A validade da sentença penal está condicionada à verdade. Portanto, exige uma motivação que deve ser de fato e de direito. A verdade de fato somente é alcançada com um processo de construção cognitiva aprofundado e metódico que traga à entidade decidente a certeza necessária para a condenação.

É exemplo de Direito Penal autoritário aquele que não se manifesta através de decisões alicerçadas sobre a verdade processual e sim, sobre outros valores que dão margem a um espaço de incerteza e ao "poder" de disposição judicial (decisionismo).

Esta insegurança, se contemplada pelos Juizes, aviltará inexoravelmente as garantias que orientam o jus poenale e o processo penal do Estado Constitucional de Direito. Tal cenário anuncia indesejável retrocesso que não conta com o entusiasmo deste magistrado.

Havendo duas versões igualmente possíveis e devidamente calcadas em provas e contraprovas, no Direito Penal não se pode simplesmente optar por aquela que desfavorece o réu.

Parafraseando Ferrajoli registro que a jurisdição sem razão não é juris-dictio. É apenas dictum. Veritas, non auctoritas facit iudicium. (A verdade, não a autoridade faz a justiça).

O mesmo autor leciona que "é iníquo não só o juiz obtuso, que não sabe captar as conotações específicas do caso julgado, mas também o que faz pesar sua subjetividade no julgamento, sem conseguir e talvez sem sequer tentar desprender-se dela para compreender a do acusado."

Nicola Flamarino Dei Malatesta, na clássica obra - A lógica das provas em matéria criminal - pontifica ipsis verbis:

"[...] o princípio e o fim da pena levam a uma mesma conclusão : a pena deve atingir aquele certamente réu. [...] E, em verdade, tendo a sociedade ofendida direito de punir o réu, não tem, contudo, o direito de ver sacrificada uma vítima em seu altar, qualquer que seja, culpada ou inocente; não: o direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do acusado e não se oprime o direito da sociedade."(destaques do Juízo)

Sopesando o conjunto probatório não é possível, portanto, concluir com a necessária segurança e certeza, que o corréu Brayan tenha auxiliado Douglas em qualquer momento da traficância apurada neste processo.

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de págs. 72/73, para CONDENAR DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA MAMEDE pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 69 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social razão pela qual não influencia negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tal circunstância judicial se analisada em detrimento do réu evidencia acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Acerca da personalidade do réu possível ligeiro acréscimo diante da execução de medida sócio-educativa na menoridade, conforme pgs. 26.

Embora seja indubitável que os atos infracionais não possam ser considerados para agravar a pena a título de maus antecedentes (na primeira fase) ou reincidência (na segunda fase), as condenações experimentadas na menoridade evidenciam a personalidade desajustada, pois se foi condenado é porque encontrava-se em conflito com a Lei. Vale lembrar que somente é considerado ato infracional aquela conduta prevista como crime ou contravenção - art. 103 da Lei 8.069/1990.

A personalidade é uma só, pois a pessoa é a mesma. Trata-se de atributo indissociável do indivíduo. O Juízo não pode identificar razão para desconsiderar os malfeitos que maculam o histórico de vida do réu, considerando-o como se fosse um indivíduo de caráter adequado e ajustado aos anseios sociais. O indivíduo que desde a menoridade coloca-se em conflito reiterado com a Lei sujeita-se ao agravamento de sua pena, sob pena de injustiçar-se aqueles que mantiveram conduta ilibada durante a menoridade, adequando-se às normas de bom convívio social.

Merece suportar acréscimo de 1/6 em sua reprimenda, diante da personalidade voltada para o injusto, vilipendiando bens jurídicos desde a menoridade, sem emendar-se.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas (neste caso insuficiente para gerar acréscimo na pena, pois a apreensão foi de cerca de 11,3 gramas, conforme massa líquida apontada no laudo pericial de págs. 173/175.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analizando estes itens o Juízo não encontra campo para acréscimo.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 um sexto acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

O réu é primário, conforme folhas de antecedentes (págs. 26/30).

Primário e de bons antecedentes, o réu faz jus à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Na decisão de pgs. 218/220 constou que "As circunstâncias indicadas na decisão de pgs. 168 ainda não estão confirmadas por certidões adequadas que deverão ser solicitadas ao i. Juízo da Infância e Juventude acerca dos processos correlacionados nas pgs. 26. A eventual dedicação a atividades criminosas desde a menoridade será melhor avaliada na sentença."

Nota-se que a única execução de medida sócio educativa foi extinta aos 11.08.2014, ou seja, mais de cinco anos antes dos fatos tratados nesta ação penal. Destarte, embora este Juízo tenha firme posicionamento no sentido de que atos infracionais podem ser reconhecidos como óbice à minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pela sua adequação ao impeditivo de "dedicação a atividades criminosas", não há dúvidas de que deve haver certa contemporaneidade entre os atos análogos a crimes praticados na menoridade e aqueles que se seguem na maioridade.

No caso concreto, passados mais de cinco anos entre o ato infracional e o crime, não há falar-se em "dedicação".

Considere-se, ainda, o fato de que aquela medida sócio-educativa foi utilizada para agravar a pena base diante da personalidade desajustada do réu, não podendo ser novamente invocada sob pena de bis in idem.

Sendo a quantidade de drogas incapaz de evidenciar ligação com organização criminosa, cabível a redução em 2/3 para fixar a pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Diante do reconhecimento incidental da inconstitucionalidade regime inicial fechado para o tráfico de drogas privilegiado (HC 111.840 27.06.2012 Rel. Min. Dias Toffoli), impõe-se a fixação do regime inicial ABERTO, notadamente diante da detração pelo tempo de prisão cautelar.

O Egrégio STJ revogou sua súmula 512 para acompanhar o entendimento do E. STF e tem reiteradamente concedido habeas corpus contra decisões do E. TJSP.

A propósito: Habeas Corpus nº 391.654/SP (2017/0052379-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.06.2017; Habeas Corpus nº 509.578/SP (2019/0133777-0), STJ, Rel. Antônio Saldanha Palheiro DJe 16.05.2019. Habeas Corpus nº 394.704/SP (2017/0074889-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.05.2017; Habeas Corpus nº 386.049/SP (2017/0013012-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 19.05.2017.

Em caso análogo, ao apreciar a apelação nº. 0000032-53.2016.8.26.0613, a Colenda 2ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença

condenatória proferida por este Juízo, mantendo igualmente a determinação de que o réu inicie o cumprimento da pena sob o regime aberto.

Também a 12ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação nº 0000322-85.2016.8.26.0575 desta comarca manteve o regime inicial aberto com expressa alusão às Súmulas 718 do STF e Súmula 440 do STJ, bem como ao HC STF nº 118.533.

A 16ª Câmara Criminal seguiu o mesmo norte na Apelação nº 0001003-55.2016.8.26.0575 desta Comarca, em acórdão da Relatoria do Eminentíssimo Desembargador Guilherme de Souza Nucci.

Descabida, no entanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a medida não se mostra socialmente adequada, tampouco suficiente para a reprovação do tráfico de drogas que, em última análise, constitui conduta que representa grave ameaça não a uma pessoa específica, mas a toda a sociedade.

A despeito da resolução nº 5/2012 do Senado Federal. Neste ponto, anoto que malgrado o assentado, v.g, no HC. 101.291 – SP, relatado pelo Ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, cerro fileiras com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no incidente de arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus nº 120.353 – SP, cujo relator é o Ministro Ari Pargendler, pois a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição citada no dispositivo invocado.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos de Sua Excelência no sentido de que “se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio artigo 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base de violência ou grave ameaça à pessoa – e com maior razão.”

No mesmo diapasão: Apelação nº 001224186.2010.8.26.0153, comarca de Cravinhos. Rel. Francisco Bruno, j. 16.06.2011; Apelação 990.09.063232-1, comarca de São José dos Campos. Rel. Newton Neves, j. 17.05.2011.

Ausente, portanto, o requisito do inciso III do art. 44 do Código Penal.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's cada. Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

A cobrança fica suspensa na forma do art. 98, § 3º do NCPC c.c art. 3º do CPP, pois o réu está patrocinado por advogado dativo, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão em regime aberto. Faculta-se ao réu apresentar-se diretamente em Juízo, evitando a intervenção policial para o cumprimento do mandado de prisão em regime aberto. Caso assim proceda, sua audiência admonitória será "encaixada" na pauta regular, nos dias úteis, entre às 13:00 e 18:30, evitando-se

eventuais sobressaltos que podem ocorrer de maneira absolutamente excepcional no cumprimento de mandados de prisão por força policial.
Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;
DECRETO o perdimento do dinheiro apreendido, pois trata-se de proveito do crime de tráfico de drogas.
Se patrocinado por advogado dativo, honorários na forma do convênio OAB-DPE.

JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER BRAYAN RICHARD SILVA REIS pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, o que faço nos termos do inciso VII do art. 386 do CPP.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Sao Jose do Rio Pardo, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA